

1502540-59.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... função diversa no esquema, enquanto a adesão ao tráfico de drogas ficou provada. Sobre a temática, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas, sequer contestadas pelo apelado - Decisão condenatória que se impõe diante da constatação de que o recorrido desenvolvia atividades típicas do tráfico de drogas em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502540-59.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502540-59.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267908/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 20587133 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2267908 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLAUDIO MOURA DE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLÁUCIO ROBERTO BRITTES DE ARAUJO

VISTOS.

CLAUDIO MOURA DE OLIVEIRA e NÍCOLAS SILVA SOUSA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e KLEBER WESLLEY ARAUJO CARVALHO foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal e no artigo 307 do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Ampère, altura do nº 20, bairro Picanço, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, agindo em concurso e

com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 10 (dez) tijolos de cocaína na forma petrificada (crack), com peso líquido de 4.740g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 19/20 e Laudo de Constatação a fls. 27/29).

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas e no 2º Distrito Policial de Guarulhos, situado na Rua Mena, nº 329, bairro Santa Mena, nesta cidade e Comarca, KLEBER WESLEY ARAUJO CARVALHO atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, e para causar dano a outrem (seu irmão "Klesley Wesley Araujo Carvalho").

A denúncia foi oferecida (fls. 160/164). Os réus foram notificados (fls. 223, 225, 227) e apresentaram respostas à acusação (fls. 217/218; 220; 237/238). A denúncia foi recebida e, não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 239/240).

Em instrução regular, foram ouvidas duas testemunhas da acusação, uma testemunha do juízo (Gabriel Roberto Antunes de Oliveira), seguindo-se os interrogatórios dos acusados.

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, na primeira fase, pediu o aumento da pena devido aos maus antecedentes, quantidade e natureza das drogas apreendidas e, na segunda, o reconhecimento da reincidência. Na terceira fase, manifestou-se pela impossibilidade de aplicação do redutor. Bateu-se pelo regime inicial fechado e, por fim, pela extração de cópias dos autos para instauração de inquérito policial pelo crime de falso testemunho contra Gabriel Roberto Antunes de Oliveira.

A Defesa de Nicolas (fls. 295/315) postulou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação da pena mínima, do art. 44 do CP, adoção do regime semiaberto, com detração, fixação da pena de multa no mínimo legal, além do encaminhamento da cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Civil para apuração das agressões sofridas pelo denunciado quando de sua prisão, em 30/09/2021.

A Defesa de Kleber (fls. 316/325) requereu a absolvição com fulcro no art 386, incisos V e VII do CPP e, subsidiariamente, no tocante ao crime de tráfico de drogas, a desclassificação para o art. 37 ou 35 ambos da Lei 11.343/06. Com relação a dosimetria, insistiu na adoção da pena no mínimo legal, aplicação do regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade.

A Defesa de Cláudio (fls 326/332), em síntese, requereu a absolvição com fulcro no art 386, inciso VII do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação, pelo laudo pericial e pela prova oral colhida em Juízo.

A quantidade e forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da posse, a confissão parcial de Nicolas e os depoimentos evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art.

33, da Lei 11.343/06. A autoria é igualmente indubitosa, considerando todo o conjunto probatório.

O réu Cláudio negou vagamente a prática delitiva, alegando que estava apenas bebendo na adega, quando os policiais o abordaram e o levaram para dentro. Não viu a mochila e alegou que os policiais perguntaram quem tinha passagem. Depois de confirmar que tinha antecedentes, inclusive por tráfico, acabou sendo conduzido ao DP. Não conhecia Kleber e Nicolas, não sabendo a razão de o primeiro também ter sido levado ao DP. Destacou que mora bem longe do estabelecimento e que era a segunda vez que lá bebia. Não declinou os motivos para tanto ou com quem estava e por qual razão foi beber tão distante de casa. Alegou que houve também agressão contra Nicolas e que não conhecia ninguém. Admitiu que não conhecia os corréus e os policiais e que tinha acabado de chegar ao bar. Em seguida, mudou sua versão, ao ser confrontado com testemunho de defesa, afirmando que falou com uma senhora e um rapaz, antes de buscar a droga. Não soube fornecer nenhum dado dessas pessoas que teriam sido liberadas, segundo suas afirmações.

Kleber também negou a prática delitiva, afirmando que estava de costas para a rua, comprando produtos para sua filha na adega, quando os policiais abordaram todos os clientes. Forneceu o seu nome verdadeiro e os policiais verificaram que era foragido, razão pela qual chegaram a lhe dizer que seria prejudicado. Somente do delegado ficou sabendo que estava autuado por tráfico. Admitiu que tem passagem pelo mesmo artigo e que tem uma adega, sem justificar a compra num estabelecimento similar.

O réu Nicolas confessou a prática delitiva, afirmando que fez a negociação de doze quilos de cocaína com indivíduo de alcunha Robinho por grupo de WhatsApp e combinou a entrega no local. Afirmou que, ao chegar, foi abordado pelos policiais que estavam numa viatura descaracterizada e levou uma coronhada.

As versões vagas, isoladas e inverossímeis prestadas em juízo por Cláudio e Kleber acabaram refutadas pelas provas colhidas, ao passo que a confissão, ainda que parcial, de Nicolas contou com sólido respaldo probatório.

A testemunha Fagner declarou que estavam em patrulhamento preventivo e visualizaram os réus, os quais ao verem a viatura caracterizada ficaram nervosos. Visualizaram Nicolas entregando drogas a Cláudio. Assim, efetuaram a abordagem e localizaram as drogas na mochila de Nicolas.. No local, ao serem indagados Nicolas disse que estava entregando a droga para Cláudio. Indagado, Kleber alegou que estava apenas acompanhando Cláudio e Nicolas e que não sabia das drogas, mas não justificou o nervosismo, nem o que fazia no local. Além disso, forneceu o nome do irmão, tendo sido constatado posteriormente que ele era foragido. Respondeu à defesa que os réus estavam a pé e que não se recordava de nenhuma moto no local. Negou que tivesse ocorrido resistência por parte de algum dos abordados, afirmando desconhecer o motivo de terem sido constatadas lesões em Nicolas. Confirmou que houve apoio, mas que as viaturas não estavam caracterizadas. Ressaltou que não houve resistência e agressões, afirmando que apenas mandaram sete ou oito pessoas deitarem para a abordagem.

A testemunha Adriano confirmou que estavam passando pelo local, em patrulhamento de prevenção, quando os réus revelaram nervosismo com a presença da viatura. Um deles entregava a mochila para o outro na porta de um estabelecimento, sendo que o terceiro estava ao lado deles. Aduziu que, na mochila, localizaram os tijolos de cocaína e que um deles confirmou a responsabilidade pelo material. Não se recordou de cada um dos réus e da situação de cada um dos abordados, salientando que ficou mais na contenção e que o parceiro foi o responsável pela abordagem. Destacou que um deles de fato forneceu nome falso, mas que não saberia dizer se exibiu algum documento. Não se recordou, ademais, se foram conduzidos em viaturas separadamente.

A testemunha de defesa Gabriel afirmou que o cliente de sua adega, Nicolas, estava no local, além de uma senhora e um rapaz jovem. O réu saiu de moto e retornou com uma mochila. Destacou que a polícia chegou ao local e abordou todos. Cláudio e Cléber estavam dentro do estabelecimento, enquanto Nicolas estava fora. Afirmou que a senhora e o rapaz foram liberados e que, somente depois do surgimento do carro branco, é que as viaturas chegaram ao estabelecimento. Foi conduzido e ouvido, mas liberado, não sabendo a razão de não terem registrado o seu depoimento. Não soube declinar possíveis motivos para apenas Cláudio e Cleber terem sido levados indevidamente ao DP e terem ficado detidos.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. No dia referido, policiais civis que efetuavam patrulhamento de rotina na região avistaram os réus em atividade criminosa. Nicolas trazia consigo uma mochila, em frente a uma adega, e a entregava a Claudio, acompanhado por Kleber. Os acusados, ao notarem a viatura policial, demonstraram nervosismo, razão pela qual os policiais efetuaram abordagem. Indagados, Nicolas confessou que estava levando as drogas para Claudio. Claudio confirmou informalmente que as drogas lhe pertenciam, enquanto Kleber apenas disse ser seu amigo. Porém, ao ser indagado sobre sua qualificação, Kleber se apresentou como Klesley, sintomaticamente. Em solo policial, Kleber novamente se apresentou como "Klesley Wesley Araujo Carvalho", mas, após a colheita de suas digitais (fls. 18), acabou confessando sua verdadeira identidade, dizendo ter mentido porque estava procurado pela justiça.

Com efeito, observa-se que a confissão judicial de Nicolas, ainda que parcial, encontrou sólido amparo nas provas produzidas. Não permaneceu isolada e foi corroborada por várias declarações. Nenhum dado concreto a abalou. Não há que se falar, portanto, em eventual insuficiência, por seu valor relativo, da confissão judicial, já que esta, no caso dos autos, está amparada por vários elementos probatórios, mormente depoimentos harmônicos. Nesse sentido, transcreve-se lição de Guilherme de Souza Nucci: "(...) a confissão ganha qualquer outra prova. Até certo ponto ela as transcende; elemento no cálculo da verdade, ela é também o ato pelo qual o acusado aceita a acusação e reconhece que esta é bem fundamentada; transforma uma afirmação feita se ele em uma afirmação voluntária. Pela confissão, o próprio acusado toma lugar no ritual de produção da verdade penal". (Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: RT, 2012, p. 470).

Enfim, Nicolas assumiu que portava o entorpecente para entrega, deixando apenas de delatar os demais, como soi acontecer, mas também sem fornecer dados para identificação e explicar o que teria ocorrido com os supostos destinatários. O conteúdo do seu integrorratório, além disso, não coincide fielmente com a versão dos corréus e da testemunha de defesa. No mais, sua confissão sobre sua conduta principal foi corroborada pelos depoimentos dos policiais e elementos sensíveis da infração.

Por outro lado, no tocante a Cláudio e Kleber os testemunhos atestaram, em unísono, com detalhes, coerência e firmeza, o recebimento conjunto e a posse das drogas, enquanto as defesas não souberam relatar dinâmica diversa de maneira convincente e não cogitaram de motivo plausível para eles serem falsamente incriminados. Também não provaram o álibi frágil invocado, além de permeado por contradições e lacunas e desprovido de sentido lógico. Não é crível, outrossim, que aquela quantidade de droga se destinaria apenas ao uso pessoal. Não obstante os argumentos das Defesas, as provas da autoria são fartas, não tendo surgido nenhum dado convincente capaz de infirmá-las.

Com relação a Cláudio, cabe salientar que este sequer morava perto da adega, não tendo apresentado qualquer explicação razoável para apenas e justamente naquele dia ter optado por se deslocar de grande distância, a fim de tomar uma cerveja sozinho em estabelecimento desconhecido. Ademais, os policiais asseguraram que o viram recebendo a mochila e que ouviram sua confissão informal de que era o destinatário

e virtual dono das drogas.

No que pertine a Kleber, ao contrário do aludido pela defesa, não há indícios que somente fora preso em virtude do mandado de prisão pendente contra si, uma vez que indicou o nome de seu irmão quando da abordagem. Aquela remota hipótese, aliás, não seria excludente do flagrante, mas justamente revelaria a lisura dos policiais, que, se imbuídos do intuito de vê-lo preso, apenas cumpririam a ordem judicial, prescindindo da falsa incriminação, sobretudo em local público, sujeitando-se ao risco de responsabilização penal e funcional, sem nenhuma perspectiva de vantagem pessoal. De qualquer modo, extrai-se dos dados concretos dos autos que os policiais desconheciam o mandado de prisão expedido em seu desfavor. A fiel qualificação do acusado apenas se deu em solo policial. Não é verossímil, outrossim, que o delegado, então, tivesse resolvido atribuir a participação no tráfico também a quem tinha sido apenas conduzido para “averiguação”, sobretudo quando já ficaria preso por outra infração. Mais absurda ainda a ideia de que o acusado, na companhia de Claudio, tivesse ido à adega comprar produtos para a sua filha. Nenhum testemunho, como se não bastasse, ou indício de verossimilhança amparou suas alegações ou as de Claudio, enquanto os testemunhos foram firmes na narrativa de que estavam juntos, recebendo as drogas de Nicolas, tanto que Kleber mentiu sobre sua identidade.

Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal. Os servidores públicos não teriam motivo para abordar inocentes desconhecidos, atribuindo-lhes a relação com 10 tijolos de cocaína, quando já tinham detido o transportador (mula). Não há prova cabal de que os policiais tivessem forjado o flagrante e as provas, nem de alibi convincente. O emprego de viatura descaracterizada é usual, visando justamente evitar a fuga de suspeitos e em nada macula a prova colhida. Saliente-se que tais testemunhos insuspeitos merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

Nesse sentido, os relatos dos policiais, nas duas fases procedimentais, restaram minuciosos, harmônicos, seguros e condizentes com os elementos sensíveis da infração. Não havia motivos, a propósito, para incriminarem falsamente

desconhecidos, sem nenhuma perspectiva de benefício pessoal, submetendo-se ao risco de perda de emprego e imposição de pena. Também não sugeram indícios de que a droga pertencesse a outrem, de vício ou de equívoco no flagrante. O fato do policial Adriano não ter se recordado de cada um dos réus e da situação de cada um em nada afasta a credibilidade de seu relato, até mesmo porque salientou que ficou responsável pela contenção, enquanto o seu parceiro realizava a abordagem. Além do tempo decorrido e das mudanças físicas naturais, das adversidades à memorização e reprodução não se extrai conclusão pelo falso testemunho. Ele assegurou que os três estavam juntos, sendo evidente o liame com as drogas, a par das confissões espontaneas. Ademais, no inquérito, havia especificado a conduta de cada um, como fez seu colega em juízo.

As imagens acostadas aos autos a fls. 279/283, ao contrário do aludido pela defesa de Cláudio, apenas corroboram o que foi narrado pelos policiais, tanto em sede policial como em juízo, mormente que estavam em uma viatura descaracterizada e viram a ação criminosa na porta do bar. A mera presença de uma mulher nas fotos acostadas não comprova que ela seria a responsável pela traficância ou apenas estava passando pelo local dos fatos, muito menos que tivesse sido liberada e favorecida, intencionalmente, pela polícia para que pudesse incriminar os corréus, o que, aliás, seria desnecessário.

Não há que se falar, outrossim, na ocorrência de flagrante forjado ou preparado. A regularidade do flagrante foi devidamente analisada na audiência de custódia. Não há um só indício nos autos de que os policiais civis em conluio com a mulher que aparece nas imagens tenham instigado os réus a realizarem a ação criminosa. Ora, as drogas foram localizadas dentro da mochila de Nicolas, réu confesso, sendo impossível que os policiais imperceptivelmente tivessem escondido aquele volume e, eficazmente, determinado que os réus se reunissem naquela local e hora. No caso concreto, os policiais apenas acompanharam a consumação do ilícito, sem qualquer provocação ou induzimento. O transporte, a posse e o recebimento, com auxílio do terceiro, apenas foram detectados a tempo de efetivação do flagrante.

E o decreto condenatório não se baseia tão somente nos dados do inquérito ou palavra de policial. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

“(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto”. (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

As provas convergentes da autoria preponderam sobre a impressão de testemunho vago, confuso, contraditório e fantasioso do responsável pelo local do tráfico e sobre as negativas genéricas e pífias de dois dos réus. A propósito, essas são desprovidas de sentido lógico e de suporte indiciário mínimo. Nada ampara a

conspiração cósmica invocada pelas Defesas contra pessoas que sequer eram conhecidas dos policiais previamente, por ocasião do flagrante.

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida, circunstância até mesmo impossível haja vista a vasta quantidade de cocaína apreendida.

De qualquer sorte, a quantidade, e forma de acondicionamento da droga, a confissão espontânea de Nicolas e as circunstâncias da ação revelaram sobejamente a destinação a terceiros. É comum, aliás, mesmo o usuário comercializar, sobretudo para sustentar o vício. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou eventual desclassificação para art. 28, da lei.

No mesmo sentido, inviável desclassificação para os delitos tipificados no art. 35 ou 37 da Lei de Drogas. Com relação ao art. 35 não foram realizadas investigações prévias que comprovassem que os réus tinham se unido previamente com o propósito específico e estável de traficar. De outro giro, a composses da droga, devidamente apreendida, foi apurada com êxito. Em tese, houve apenas o concurso de agentes esporádico e momentâneo. Ademais, foi provado o dolo genérico de possuir droga ou concorrer para a posse, destinada à distribuição, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabendo, destarte, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/06. Neste sentido:

“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para associação (art. 35 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 35 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande quantidade de substância estupefaciente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 O fato da apreensão ser concernente a elevada quantidade de substância estupefaciente ilegalmente transportada afasta a possibilidade de incidência da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez ser indicativa de que os acusados se dedicam a atividade criminosa.” (TJSP; Apelação Criminal 0005070-40.2013.8.26.0358; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/05/2016; Data de Registro: 19/05/2016)

No mesmo diapasão, impossível a desclassificação para a conduta prevista no art. 37, da Lei nº 11.343/06. No caso em apreço, os acusados foram presos na posse das drogas, que Nicolas entregava para Claudio e Kleber. Como se observa, o réu Kleber desempenhava uma função ativa, auxílio decisivo para instigar a entrega por Nicolas e, portanto, participação relevante (não de somenos importância), seja na proteção ou no transporte que iniciariam, não se tratando de mera colaboração autônoma ou atos de informação. Ademais, em nada colaborou com a polícia, tendo mentido sobre a identidade e situação verificada, e não restou comprovado nos autos que tivesse função diversa no esquema, enquanto a adesão ao tráfico de drogas ficou provada. Sobre a temática, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas, sequer contestadas pelo apelado - Decisão condenatória que se impõe diante da constatação de que o recorrido desenvolvia atividades típicas do tráfico de drogas em comparsaria e não de mero informante com grupo, organização ou associação destinado ao tráfico - Distinção entre "informante" e "olheiro" na hipótese concreta dos autos - Condenação do réu ao tráfico com o aumento de pena decorrente da participação de menor de idade no crime admitido - Penas readequadas e regime prisional fechado determinado - Recurso provido."

(TJSP; Apelação Criminal 1518050-34.2019.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020).

Os acusados são imputáveis e praticaram os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica ou dependência, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não justificam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre os réus e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

Melhor sorte não assiste ao acusado Kleber no que tange ao crime de falsa identidade. Conforme já explanado, o réu identificou-se aos policiais como "Klesley Wesley Araujo Carvalho", seu irmão, conduta típica que independa da mais grave, qual seja, exibição de documento falso. Atribuiu-se falsa identidade, outrossim, na Delegacia de Policial. Apenas após a colheitas de suas digitais no DP chegou-se à verdadeira identidade do réu. Destarte, não há que se falar na mera ocorrência de equivoco ou confusão quando de sua qualificação inicial.

A recorrente tese da falsa identidade como espécie de exercício regular de direito, especialmente como meio de autodefesa, visando ocultar seus atos infracionais, não se sustenta. O agente optou por frustrar aplicação da lei e a atividade das autoridades, obtendo vantagem (esquivar-se dos efeitos legais de determinados fatos), razão pela qual presente a tipicidade material no caso concreto. Destarte, os direitos são contrastados por outros e por deveres. A autodefesa não contempla e não depende da violação destes. Muito menos poderia ser considerado regular tal exercício.

A conduta adequa-se com perfeição ao art. 307 do Código Penal, que não leva em conta a motivação do falso, mas a capacidade de enganar e a intenção de fazê-lo. Com efeito, o dolo, no caso em apreço, restou devidamente comprovado, uma vez que o réu mentiu sobre sua identidade, fornecendo, de pronto, o nome diferente do constante do registro de nascimento e demonstrando claro intuito de ludibriar as Autoridades Policiais. A real identificação apenas foi obtida após consumação do falso (auto atribuição), não se cogitando de crime impossível.

Despicienda, até mesmo, a realização de pesquisa datiloscópia, uma vez que o crime se consuma com a auto atribuição com o fim de ocultar seus antecedentes criminais. Ademais, o crime é formal, o meio era idôneo e poderia não ter despertado a suspeita dos policiais e ainda prejudicar terceiro de boa fé. A casual averiguação ulterior da identidade não constituía falta absoluta de condições de execução a priori. Sobre a temática ora analisada, confira-se a farta jurisprudência dos tribunais superiores:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA

CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”(STF – Repercussão Geral no RE 640.139/DF – Pleno – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 22/9/2011 – DJe-198 de 14-10-2011).

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE. DIREITO À AUTODEFESA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que tanto a conduta de utilizar documento falso como a de atribuir-se falsa identidade, para ocultar a condição de foragido ou eximir-se de responsabilidade, caracterizam, respectivamente, o crime do art. 304 e do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa. 2. No caso, conforme depreende-se da imputação, no momento de sua prisão, o paciente atribuiu-se falsa identidade para eximir-se de responsabilidade penal, estando, portanto, caracterizada a tipicidade da conduta. 3. Ordem denegada.” (STJ – HC 151802/MS – 2009/0210367-5 – 6ª T. – rel.^a Min.^a Maria Thereza de Assis Moura – j. 19.4.2012 – DJe 30.4.2012).

“HABEAS CORPUS . PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. CONDUTA TÍPICA. 1. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). Precedente do Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (RE n. 640.139/DF). 2. Ordem denegada.” (STJ – HC nº 218.812-SP (2011/0222115-5) – 6ª T. – rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – j. 13.2.2012 – DJe 21.3.2012)

Destarte, restou configurada a adequação do tipo penal da falsa identidade à conduta praticada pelo acusado, sendo patente sua responsabilização criminal. O crime tanto era possível que iludiu por algum tempo as policiais e levou à necessidade de demais diligências. Não teriam e não poderiam ser feitas precocemente ou ainda na abordagem. De qualquer modo, a infração já tinha sido consumada com a falsa identificação (formal).

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, com relação a Cláudio, observo que o réu ostenta duas condenações as quais apenas podem figurar como maus antecedentes, pois já contempladas pelo período depurador (fls. 98/131), quais sejam, Processo nº 530/1999 e Processo nº 0086441-48.2011.8.26.0050, cujo trânsito em julgado se deu em 27/11/2012. Assim a pena base de Claudio é exasperada em 1/6 perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e no pagamento de 583 dias-multa.

No tocante a Nicolas consta a condenação referente ao Processo n. 0000928-05.2017.8.26.0535 (fls. 125/127), a qual será usada apenas para fins de reincidência, evitando-se o bis in idem. Destarte, a pena base é mantida no mínimo legal, consistente em 5 anos de reclusão e no pagamento de 500 dias-multa.

No que tange ao acusado Kleber, observo que o réu ostenta três condenações (fls. 116/124), quais sejam, Processo n. 0116601-22.2012.8.26.0050, cujo trânsito em julgado se deu em 25/05/2015, Processo n. 0001167-80.2016.8.26.0361 cujo trânsito

em julgado se deu em 10/03/2017 e Processo n. 0070057-05.2014.8.26.0050 cujo trânsito em julgado se deu em 17/09/2014. Assim, as penas base são exasperadas em 1/6 perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e no pagamento de 583 dias-multa (tráfico) e 3 meses e 15 dias de detenção (art. 307 do CP), utilizada a condenação relativa ao Processo n. 0001167-80.2016.8.26.0361 apenas para fins de reincidência, evitando-se o bis in idem.

Ainda na primeira fase, deixo de exasperar a pena com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, pois a quantidade foi determinante na configuração do próprio tipo penal e será considerada na definição geral da resposta, especialmente regime, descabendo aqui mais uma intensificação da severidade da sanção.

Na segunda fase, com relação ao réu Claudio, ausentes causas de aumento ou de diminuição, mantida a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão e no pagamento de 583 dias-multa.

No que tange ao réu Nicolas compenso a agravante da reincidência de cunho subjetivo com a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual, ainda que parcial, revelou algum arrependimento, condição essa favorável subjetivamente, além de representado contribuição determinante para a elucidação da verdade real, fatores que não justificam tratamento idêntico ao oferecido a quem mente em juízo. Ademais, recaiu sobre o dolo e adesão ao tráfico. Confira-se: Tema 585 do STJ: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.". A pena se estabiliza, então, em 5 anos de reclusão e no pagamento de 500 dias-multa.

No mais, no que toca ao réu Kleber, haja vista a agravante da reincidência as penas são exasperadas em 1/6 perfazendo 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e no pagamento de 680 dias-multa (tráfico) e 4 meses e 2 dias de detenção (art. 307 do CP).

Na terceira fase, com relação ao crime de tráfico, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, com relação a todos os réus, não incide a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Ainda na terceira fase, no que diz respeito ao réu Kleber, considerando os meios de execução diversos do tráfico e falsa identidade, além dos desígnios autônomos e bens jurídicos específicos, verificam-se mais de uma conduta autônoma a impor o concurso material de crimes. Ante a diferença de natureza das penas (de reclusão e detenção), inviável eventual somatória, devendo o acusado iniciar o cumprimento da condenação pela pena de reclusão, nos termos do art. 69, parte final, do CP.

No que concerne ao regime, com relação ao crime de tráfico, a gravidade do crime, sobretudo pela quantidade e natureza da droga, e os maus antecedentes e reincidência, impõem o regime inicial fechado, estando, ainda, legalmente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A quantidade da pena já obstaría a reprimenda alternativa e a vida pregressa, o regime mais brando, além de não ser a substituição socialmente recomendável. No que toca ao réu Kleber e ao crime falsa identidade, impõe-se o regime semiaberto, tendo em vista o efeito da reincidência para detenção. Inviável a aplicação do art. 44 do CP, ante a reincidência e maus antecedentes, além de não entender socialmente recomendável.

A despeito da compreensível necessidade de tempo para outorga da prestação jurisdicional de primeira instância, não é possível conceber regime diverso, mediante estimativa da detração. Além de destoar dos fundamentos da pena e vida pregressa, mormente maus antecedentes e reincidência, a aplicação de regime mais brando, sem correspondência com a disciplina legal da dosimetria, mas com base na duração da prisão provisória, é desprovida de embasamento lógico e jurídico. 0

período de prisão provisória não seria suficiente para progressão imediata perante o quantum da pena ora estabelecido, além de ausente verificação da necessidade de unificação de penas e das condições subjetivas dos sentenciados, mormente comportamento carcerário, para análise do mérito da alteração de regime. Por conseguinte, não atenderia aos princípios da individualização da pena e da isonomia substancial.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO os réus: CLAUDIO MOURA DE OLIVEIRA no cumprimento da pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, com atualização monetária, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/2006; NÍCOLAS SILVA SOUSA, no cumprimento da pena de 05 anos reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, com atualização monetária, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/2006; E, KLEBER WESLEY ARAUJO CARVALHO no cumprimento da pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, com atualização monetária, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no cumprimento da pena de 04 meses e 02 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 307 do Código Penal, ambos os delitos, na forma do art. 69 do CP.

Os réus não poderão recorrer desta sentença em liberdade, já que permaneceram presos até a presente decisão, sendo contraproducente sua soltura, neste lanço, em detrimento da aplicação da lei penal, após imposição de regime fechado. Ademais, a reincidência, maus antecedentes e a gravidade do delito, mormente pela presença de cocaína, que coloca em risco o meio social e fomenta outros crimes, tornam necessária a custódia como garantia da ordem pública. Recomendem-se os acusados no ergástulo onde se encontram. Expeçam-se guias de recolhimento, oportunamente.

Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Determino a incineração da droga apreendida.

Determino o encaminhamento da cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Civil para apuração de agressões supostamente sofridas pelo denunciado Nicolas quando de sua prisão, em 30.09.2021, como ora solicitado pela defesa e pelo MP quando da audiência de custódia.

Por fim, determino a extração de cópias dos autos para instauração de inquérito policial pelo crime de falso testemunho contra Gabriel Roberto Antunes de Oliveira, conforme requerido pela acusação, pois há indícios de quem em seu depoimento relatou fatos que sequer condizem com a narrativa dos próprios réus.

Custas e despesas processuais pelos sentenciados, respeitada a gratuidade.

P.I.C.

Guarulhos, 09 de fevereiro de 2022.

GLÁUCIO ROBERTO BRITTES DE ARAUJO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA